

1532975-66.2020.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto

Magistrado: Fernando Cesar do Nascimento

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... que demonstra a prática do delito de tráfico. Prova - Palavras dos policiais - Validade - Inexistência de motivos para incriminar o réu injustamente. Causa de aumento de pena - Artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 - Caracterização - Delito cometido no interior do presídio - Apelação do réu não provida." (TJSP, Apelação 990092195549, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1532975-66.2020.8.26.0562 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 25 de julho de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. FERNANDO CESAR DO NASCIMENTO. Eu, Matheus de Carvalho Alvarez Teruya, Assistente Judiciário, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1532975-66.2020.8.26.0562

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL MONTEIRO QUEIROZ

Vistos.

GABRIEL MONTEIRO QUEIROZ, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nos artigos 28 e 33, §3º, da Lei 11.343/2006, porque no dia 05 de dezembro de 2020 portava entorpecentes para consumo pessoal e também os ofertou para terceiro para juntos consumirem.

Não sendo o réu localizado, os autos, inicialmente distribuídos ao Juizado Especial Criminal, foram encaminhados à Justiça Comum.

A denúncia foi recebida e determinada a citação do réu por edital (págs. 62/63), a qual foi realizada a pág. 77, suspendendo o processo (pág. 86).

O réu foi então citado a pág. 98, retomando o curso processual. Foi apresentada a defesa prévia (pág. 123).

A audiência foi designada (págs. 125/126) e realizada a págs. 169/170, momento em que foram coletadas provas orais, o interrogatório e as alegações finais das partes, tendo as partes requerido a absolvição do réu.

É o relatório necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Tem-se, in casu, acusação do cometimento do crime de porte de drogas para consumo pessoal e oferecimento de drogas para pessoa de seu relacionamento, que vêm assim previstos na Lei nº 11.343/2006:

"Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo

Art. 33 § 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28."

Com a devida vênia ao pedido de absolvição realizado pelo Ministério Público, com fulcro no artigo 385 do Código de Processo Penal, tenho que o conjunto probatório é favorável à condenação, devendo a pretensão punitiva ser julgada procedente.

Consigno, inicialmente, que "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

A materialidade do delito vem comprovada pelo boletim de ocorrência (págs. 4/5), auto de exibição e apreensão (pág. 7) e laudo toxicológico (págs. 38/40) indicando a natureza das substâncias apreendidas, bem como pela prova oral coligida aos autos.

Do mesmo modo, inequívoca a autoria.

Ambos os policiais ouvidos em juízo trouxeram relato harmônico sobre o evento em voga, narrando que, em patrulhamento de rotina na orla da praia, avistaram o réu entregando algo para um terceiro ignorado próximo a um quiosque. Ao notar a aproximação dos policiais, seguiu ao banheiro e lá foi abordado. Neste primeiro momento, nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Contudo, ao verificar o local em que estava, foi achada uma porção de maconha, a qual o réu confirmou a posse, sendo em seguida por ele foi indicado outro local que também continha mais outra porção de maconha e de cocaína. O terceiro, ao qual o réu entregou a droga, não foi encontrado.

A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial, tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação.

Nesse sentido, registrem-se os seguintes precedentes:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - RT 68/64).

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese dos desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito" (Tacrím/SP - JUTACRIM 30/221).

"É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente

impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (TacrimsP - RT 530/372).

"PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador."

(Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.).

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência."

(HC 73518, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).

Na mesma direção:

"A condição de a testemunha ser Policial não a torna impedida ou suspeita para depor, devendo-se conferir à sua palavra a necessária credibilidade, decorrente da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral". (RJTACRIM 48/228).

Ainda:

"Entorpecente - Insuficiência de provas - Não ocorrência - Absolvição - Impossibilidade - Conjunto probatório seguro que demonstra a prática do delito de tráfico. Prova - Palavras dos policiais - Validade - Inexistência de motivos para incriminar o réu injustamente. Causa de aumento de pena - Artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 - Caracterização - Delito cometido no interior do presídio - Apelação do réu não provida."

(TJSP, Apelação 990092195549, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 12/01/2010, reg. 23/01/2010).

"PORTE ILEGAL DE ARMA - Quadro probatório seguro e coeso Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Prova segura - Condenação mantida - Reincidência não verificada - Réu tecnicamente primário - Substituição da pena por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Réu que praticou novo delito durante o livramento condicional - Alteração do regime para o aberto permitida - Recurso parcialmente provido para esse fim (voto 8006).

(TJSP, Apelação 990081609592, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 12/01/2010, reg. 23/01/2010).

Por outro lado, a versão apresentada em interrogatório restou ilhada nos autos e não é secundada por qualquer elemento probatório.

Afirma o réu que tinha saído da balada e estava alcoolizado. Apesar de ser usuário de maconha, no dia não tinha consumido. Na verdade, não estava no quiosque como

apontado pelos policiais, mas em um banco próximo. Foi no banheiro para urinar, momento em que o policial entrou para abordá-lo. Saiu e foi enquadrado, mas nada foi encontrado em seu poder. No momento, chegou um senhor de idade para conversar com o outro policial, não sendo permitido que ouvisse a conversa. Depois de um tempo, um dos agentes buscou uma quantidade de drogas e alegou que era dele. Na delegacia, afirma que ele foi liberado. Diz que não existiu a troca de drogas nem a indicação do local onde estariam supostamente reservadas. Confirma ser usuário e ele constantemente é enquadrado por um dos policiais que realizou a abordagem, inclusive diz que amigos próximos já discutiram com ele no passado por essa razão. Registro a mera alusão de que o policial teria se desentendido no passado por conta de outras abordagens pelo uso de drogas, por si, não implica em qualquer conclusão que possa afetar a credibilidade de seus dizeres.

O relato do réu é frágil e configura mera negativa que não pode ser tomada como bastante para afastar o conjunto probatório formado.

E, como confirmado pelo réu, ele é usuário de drogas e frequenta com terceiros também usuários a localidade em que foi feita a abordagem, a reforçar a versão dos policiais.

Diante desse cenário, não se vislumbra a fragilidade da instrução como afirmado em sede de alegações finais. A versão apresentada em depoimento não contém contradições e é fidedigna com o produzido em sede de inquérito, não existindo dúvidas sobre a dinâmica dos eventos ocorridos.

Assim, reconhecendo a veracidade dos depoimentos policiais, tanto quanto da confirmada posse das drogas encontradas e de sua entrega a terceiro antes da abordagem, restam caracterizados os delitos previstos no artigo 28 e 33, §3º, da Lei nº 11.343/06.

No tópico, imperioso ressaltar que não há que se falar em inconstitucionalidade ou atipicidade da conduta de porte de drogas para consumo pessoal.

Com efeito, embora a Lei Antidrogas não preveja pena privativa de liberdade no preceito secundário do artigo 28, tal circunstância, por si só, não implica na descriminalização da conduta.

Outrossim, não se desconhece o reconhecimento, no âmbito do C. Supremo Tribunal Federal, de Repercussão Geral quanto ao tema, nem se ignora, também, que o julgamento do mérito da matéria já se iniciou (RE 635.659/SP), mas ainda não encerrou.

Dessa forma, como tal julgamento não foi concluído, é certo que, no momento, a regra contida no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 mantém-se incólume e vigente no ordenamento jurídico, tal como tem sido, até o presente, reiteradamente reconhecido.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. CONDUTA TÍPICA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO PELO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. DESPROPORCIONALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A DEDICAÇÃO DO AGENTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MODO ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. É inviável a declaração da atipicidade da conduta do paciente pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Embora a constitucionalidade do referido artigo esteja afetada na Suprema Corte, diante do reconhecimento da repercussão geral (Tema 505), nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/RG, ainda prevalece neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não houve a descriminalização do porte de drogas para uso próprio com a entrada em vigor da Lei n. 11.343/2006, mas mera despenalização, tendo em vista a previsão de penas alternativas para o infrator ((HC n. 453.437/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/10/2018; HC 478.757/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 11/2/2019). (...) (HC 535.785/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019) (grifei).

É de se ressaltar, ainda, que por expressa previsão legal no preceito secundário do artigo 33, §3º, sua condenação não impede a aplicação das penas contidas no artigo 28, como é o caso concreto, não sendo o caso, portanto, de bis in idem da aplicação das penas correspondentes. Desse modo, a condenação é de rigor.

Passo, então, à dosimetria das penas, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal e 42 da Lei Antidrogas, obedecendo ao critério trifásico.

Quanto ao delito de oferecimento de drogas, na primeira fase, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que os motivos, circunstâncias e as consequências do crime não são especialmente reprováveis. A culpabilidade da conduta também já foi mensurada no estabelecimento dos parâmetros abstratos de pena no tipo penal incriminador. Não existem elementos para se aferir a personalidade do agente. A existência de condenação anterior também não poderá ser levada em consideração para reprovar sua conduta social, haja vista que ela será utilizada para fins de reincidência.

Assim sendo e observando o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena na primeira fase em 6 (seis) meses e 700 (setecentos) dias-multa. Na segunda fase, há de se considerar somente a agravante da reincidência, conforme condenação descrita a págs. 65/67 e 75/76, a qual majora a pena em 1/6, estabelecendo a pena de 7 (sete) meses e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. Em sequência, na terceira fase, inexistem circunstâncias que autorizem o aumento ou a diminuição da pena, mantendo-se os patamares retro descritos como definitivos. Os dias-multa terão valores mínimos legais, devido à ausência de prova da capacidade econômica do réu.

A despeito da reincidência, pela baixa gravidade do delito, a quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais favoráveis, é o caso de aplicação do regime aberto para o cumprimento de pena.

Contudo, considerando esses mesmos fundamentos traçados e que o primeiro delito que cometeu não é da mesma natureza, compreendo possível a substituição da sua pena por restritivas de direito, com fundamento no artigo 44, caput, e §3º, para prestação de serviços à comunidade, em instituição a ser designada na fase de execução.

Quanto ao delito de porte de drogas para consumo pessoal, analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, e, em observância ao disposto pelo artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar, e, seguindo as mesmas diretrizes já traçadas para o delito anterior, nada há de se acrescentar nesta fase.

O réu é reincidente, sendo, por isso, considerada para fins de aplicação de agravante.

Assim, a pena intermediária deve ser majorada.

O §3º do artigo 28, da referida Lei dispõe que a pena máxima a ser aplicada é de 05 meses, nos casos de prestação de serviços à comunidade e medida educativa e o §4º do mesmo dispositivo amplia para 10 meses esse prazo em casos de reincidência do condenado, como é a hipótese dos autos.

Entretanto, a lei não menciona o prazo mínimo. Logicamente, não é possível tratar os agentes com bons antecedentes e conduta social favorável da mesma forma que os com maus antecedentes e conduta social desfavorável.

Esse foi o motivo da lei considerar como máximo o prazo fixado, sendo imperiosa a delimitação do mínimo a ser aplicado nos casos mencionados acima.

Portanto, de forma analógica e em benefício do réu, aplico o disposto no art. 44, §4º, última parte, do Código Penal, que dispõe acerca do saldo mínimo de 30 (trinta) dias.

Dessa forma, entendo que a prestação de serviços à comunidade mínima possível é de 30 (trinta) dias, aplicável aos agentes primários, com bons antecedentes e conduta social favorável, o que não é o caso.

No caso em tela, considerando a reincidência do réu, fixo a pena em 60 (sessenta) dias de prestação de serviços comunitários.

Dispositivo.

Ante o retro exposto e todo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o réu GABRIEL MONTEIRO QUEIROZ, qualificado nos autos, por incurso nos artigos 33, §3º, e 28 da Lei nº 11.343/2006, às seguintes penas, respectivamente:

- 1) 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprido em regime inicial aberto, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa fixados em seu mínimo legal; e substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal), qual seja, a prestação de serviços à comunidade, em instituição a ser designada na fase de execução;
- 2) 60 (sessenta) dias de prestação de serviços comunitários, a ser executada nos termos do artigo 28, § 5º, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 46 do Código Penal.

Pela condenação e inexistência de motivos para segregação, concedo ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, cumpram-se as formalidades legais e, após, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Santos, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA